

1500459-60.2021.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... pois via ele indo buscar. Nega o tráfico de droga.

Em que pesem os argumentos defensivos, há prova suficiente para a condenação dos réus pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A negativa dos acusados não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, não sendo crível a versão do réu Ricardo de que estava vendendo cartões de desconto e por isso a quantia em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500459-60.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500459-60.2021.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RUFINO DE CASTRO e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

RICARDO RUFINO DE CASTRO e GUILHERME VIEIRA MARQUES, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, porque: (i) entre data não precisamente determinada, até 28 de outubro de 2021, na região da Vila Barros, nesta cidade e Comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas e (ii) no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Salvador Salgueiro, defronte ao número 1025, Vila Barros, neste município e Comarca, os denunciados traziam consigo e guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oito porções de crack, com peso de 0,91 grama e um "tijolo" de crack, com peso de 1.038,7 gramas (cf. laudos de constatação e toxicológico às fls. 44/46 e 134/139).

Foram presos em flagrante delito e houve a conversão da prisão flagrancial em preventiva (fls. 86/88). Os réus foram notificados (fl. 172 e fl. 174) e ofertaram defesa prévia (fls. 199/200). A denúncia foi recebida em 5/4/2022 (fls. 201/203) e os réus foram citados (fl. 238 e fl. 240). Em audiência de instrução e julgamento virtual, realizada em 17/5/2022 (fls. 241/242), foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e os acusados foram interrogados (fls. 212/218).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Na fixação da pena devem ser considerados os maus antecedentes e reincidência de ambos. Por este motivo, inviável a configuração do tráfico privilegiado. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado. Requer, por fim, o perdimento do aparelho celular e do dinheiro apreendido (conf. mídia audiovisual).

A Defensoria Pública, em alegações finais ofertadas às fls. 248/263, argumentou, preliminarmente, que a confissão informal do réu Guilherme é ilícita por não observar o direito ao silêncio e, por consequência, as demais provas dela derivadas.

Além disso, ponderou que não há prova do vínculo associativo e permanente entre os réus para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, aplicação de pena base no mínimo legal, incidindo apenas a agravante da reincidência na segunda fase a fim de evitar “bis in idem”, com a fixação de regime prisional abrandado, além de observação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Preliminarmente, afasto os argumentos defensivos de que a prova obtida é ilícita.

Analisando o contexto, tem-se que os policiais, munidos de informações prévias, realizaram várias diligências na Vila Barros no período da manhã, no intuito de flagrar a distribuição de droga efetuada pelo réu Ricardo. Na data dos fatos, lograram êxito em localizá-lo na companhia do réu Guilherme e ambos, ao avistá-los, empreenderam fuga. Abordados pouco depois, o acusado Guilherme afirmou que havia dispensado uma bolsa e dentro dela localizaram droga. Ao ser questionado, ele fez a confissão informal de que traficava e que havia mais entorpecentes escondidos próximo a um córrego.

O fato é que a apreensão da pedra de “crack” não decorre diretamente da confissão informal, mas a partir de informações prévias de distribuição de entorpecente naquele horário e local, culminando com a abordagem e localização de droga após a intensa busca efetivada na área pela polícia, motivo pelo qual considero idônea a prova obtida. A par disso, eventual irregularidade na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar o processo, especialmente se as provas são ratificadas em Juízo, como a análise do mérito apontará.

No mais, a existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o auto de prisão em flagrante de fls. 4/5, boletim de ocorrência de fls. 33/36, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 37/38, pela fotografia de fl. 39, pelos laudos de constatação provisória de fls. 44/46 e laudo químico toxicológico de fls. 134/139, este atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína – na apresentação popularmente conhecida por crack), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 142/147) e prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Edenyr Alfredo Bedusqui e André Luis de Oliveira, policiais civis, declararam terem recebido informações prévias de que o réu Ricardo, vulgo, "Café" praticava o tráfico de drogas na Vila Barros, abastecendo suas "biqueiras" com entorpecente pelas manhãs. Diversas vezes circularam pelo local nesse período, tentando flagrá-lo. Na data dos fatos avistaram o réu Ricardo, na companhia do réu Guilherme, subindo por uma das vielas da comunidade. Quando avistaram os policiais, ambos tentaram fugir. O réu Ricardo foi abordado praticamente no local e com ele havia 3 porções de crack e R\$ 200,00. O réu Guilherme foi abordado a 50 metros do ponto inicial. Ele admitiu ter dispensado uma bolsa, que foi localizada, contendo 5 porções de crack e R\$117,00. Ao ser questionado sobre os fatos, o réu Guilherme confessou informalmente que estava vendendo drogas para o réu Ricardo, indicando, inclusive, que Ricardo guardava mais entorpecente nas proximidades de um córrego que há no local. De fato, após uma varredura no local, encontraram um tijolo de crack.

O réu Ricardo Rufino de Castro declarou que na data dos fatos estava trabalhando na comunidade, vendendo um cartão que dá descontos. Estava com a quantia de R\$200,00, referente a adesões ao cartão. Ele foi abordado pelos policiais, que disseram que estavam realizando apenas uma averiguação. Posteriormente, foi acusado de tráfico de drogas, o que não é verdade. Além disso, não conhece o réu Guilherme.

O réu Guilherme Vieira Marques, interrogado, declarou que na data dos fatos foi até o local para adquirir porções de crack, pois é usuário. Adquiriu a droga do réu Ricardo e por isso sabia onde ele guardava a maior parte do entorpecente, pois via ele indo buscar. Nega o tráfico de droga.

Em que pesem os argumentos defensivos, há prova suficiente para a condenação dos réus pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A negativa dos acusados não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, não sendo crível a versão do réu Ricardo de que estava vendendo cartões de desconto e por isso a quantia em dinheiro encontrada em seu poder, não fazendo prova de qualquer talonário ou impresso capaz de sustentar o alegado.

Outrossim, o réu Guilherme disse ser apenas usuário e que foi ao local para comprar a droga de Ricardo e, por tal motivo, conhecia o local de guarda do entorpecente. Contudo, sua versão está isolada do contexto probatório. Em sede policial, não faz menção ao uso de tóxicos ou de internação para tratamento de dependência química (fls. 9/10), salientando-se que é possível a figura do usuário estar atrelada à do traficante.

Em contrapartida, os relatos dos policiais civis foram coesos e uníssonos no sentido de que receberam informações prévias apontando que o sentenciado Ricardo fazia a distribuição da droga para as "biqueiras" no período da manhã. Diligenciaram por diversas vezes pela Vila Barros, até localizá-lo na data dos fatos na companhia do réu Guilherme.

Também ofertaram detalhes da abordagem e a apreensão de entorpecente com ambos os réus, além da localização de quantia maior nas imediações.

E não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado juiz como qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput). Segundo, porque os depoimentos de policiais compõem naturalmente o contexto probatório e inexistem indícios de que tenham interesse de causar gratuito e falso prejuízo aos acusados.

Embora pouco expressiva a quantidade de entorpecentes localizada na posse dos réus, ambos traziam quantidade razoável de dinheiro sem comprovação de origem lícita e pouco usual para um mero usuário.

Apesar de não narrarem situação de comercialização, as condutas periféricas como trazer consigo, guardar, transportar ou mesmo manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do tipo penal. Neste sentido, é o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06, assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o depósito e a guarda do entorpecentes, hipótese dos autos." (STJ, Quinta Turma, HC 210.746/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 26/06/2012, DJe de 01/08/2012).

Notório, ainda, é que a natureza da droga encontrada com os sentenciados era compatível com àquela porção maior encontrada nas adjacências e que, certamente, seria destinada ao fracionamento.

Portanto, a partir das informações prévias, a diligência resultou positiva e a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Nos termos do disposto no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, existe a convergência de algumas situações indicativas do tráfico de entorpecentes, tais como: a) as informações prévias apontando que o réu Ricardo fazia o abastecimento das "biqueiras" no período da manhã; b) a atitude suspeita dos réus que empreenderem fuga ao notarem a aproximação da Polícia; c) as somas em dinheiro, em notas diversificadas, localizadas com cada réu sem comprovação de origem lícita; d) a apreensão de "crack" embalado em porções individuais e de tablete com grande quantidade da mesma droga destinado ao fracionamento;

Como se vê, a prova oral está em consonância com a prova pericial que instrui os autos, inexistindo qualquer discrepância acerca da dinâmica dos fatos e revelando, sem qualquer dúvida, a ocorrência do comércio de drogas, bem como a autoria do crime.

Tratando-se, especificamente, do delito de associação para o tráfico, com razão a Defensoria Pública. Embora haja indícios de unidade de propósitos entre os acusados, não há provas efetivas da ocorrência do crime e, por esta razão, a absolvição dos réus é medida que se impõe.

O liame subjetivo característico da associação não foi demonstrado nos autos. Não se sabe se a traficância se dava de forma habitual e permanente ou se foi uma situação isolada e não há nada a respeito de hierarquia ou divisão de tarefas bem definidas entre eles.

Nesse sentido o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

"Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006." (STJ - AgRg no HC 539.907/RJ T5 - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. em 17.12.2019 DJe em 19.12.2019).

Portanto, denota-se pelas provas coligidas que houve a completa subsunção da conduta dos réus ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em relação ao réu Ricardo Rufino de Castro, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois ele ostenta maus antecedentes (processo nº 0003682-59.2011.8.26.0104 - trânsito em julgado em 12/7/2017 - fl. 51). Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Já em relação ao réu Guilherme Vieira Marques, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, posto que o único registro presente nas certidões criminais será sopesado na fase seguinte (fls. 63/65). No mais, a culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante consistente na reincidência do acusado Ricardo Rufino de Castro (processo nº 0023133-87.2015.8.26.0344 - fls. 52/53 - trânsito em julgado em 19/6/2018 e processo nº 0030776-04.2012.8.26.0344 - fl. 54 - trânsito em julgado em 13/7/2018), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, perfazendo a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Da mesma forma, ainda na segunda fase, presente a agravante da reincidência relativa ao réu Guilherme Vieira Marques (processo nº 1510736-77.2019.8.26.0344 - fl. 64 - trânsito em julgado em 16/3/2021), devendo a pena ser majorada em 1/6 o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

O agravamento da sanção por tais fatores não constitui dupla punição pelo mesmo fato, tratando-se, em verdade, da individualização da pena dos acusados que, já condenados definitivamente por outros ilícitos, voltaram a praticar crime e, por isso mesmo, devem ser mais severamente responsabilizados.

Na terceira fase, ausente causas de aumento. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e a reincidência dos réus.

A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no dispositivo legal mencionado acima, haja vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o réu seja primário. E por ser a reincidência apenas um dos requisitos que impede a incidência do benefício penal, não sendo elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em bis in idem.

Desta forma, torno definitiva a pena do acusado Ricardo Rufino de Castro em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e

oitenta) dias-multa e do acusado Guilherme Vieira Marques em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas condições econômicas dos réus, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu RICARDO RUFINO DE CASTRO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, e o réu GUILHERME VIEIRA MARQUES, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para ABSOLVÊ-LOS da imputação descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que os réus são reincidentes e dada a gravidade do delito, que é equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não terem atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Registro, ainda, que apenas o Juízo das Execuções possui o quadro completo das condenações dos acusados, comportamento carcerário e de merecimento e, portanto, pode realizar a detração com maior rigor e acuidade.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Os réus tiveram a prisão preventiva decretada (fls. 86/88) em virtude da prisão em flagrante com considerável quantidade de entorpecente altamente nocivo, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerados durante o curso do processo, restando claro que ainda persistem os requisitos para manutenção da custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Além disso, os registros anteriores de ambos os sentenciados denotam reiteração delitiva que deve ser coibida para garantia da ordem pública. Destarte, mantenho a prisão preventiva dos sentenciados, que não poderão recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomendem-se os réus no presídio em que se encontram recolhidos.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o artigo 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do bem consistente no numerário objeto dos depósitos judiciais de fls. 140/141 e no aparelho celular apreendido à fl. 37/38.

Autorizo, ainda, a destruição dos bens antieconômicos.

Sem prejuízo, considerando que o auto de exibição e apreensão denota que houve a apreensão da quantia de 117,00 (cento e dezessete reais) e que os depósitos judiciais de fls. 140/141 referem-se ao valor de 200,00 (duzentos reais), oficie-se à Autoridade Policial pelo envio do expediente para juntada nestes autos e posterior deliberação.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA